

1500463-12.2022.8.26.0416

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Panorama

Foro: Foro de Panorama

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... tudo a indicar que se dedicava e fazia do tráfico seu meio de vida.

De outra parte, a circunstância de ser o réu usuário de drogas também não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, pois nada impede que as figuras de usuário e traficante recaiam sobre a mesma pessoa.

No mesmo sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Panorama

Foro de Panorama

2ª Vara Judicial

Rua Manoel Fernandes da Cunha, nº1308, Panorama-SP - cep 17980-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500463-12.2022.8.26.0416 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500463-12.2022.8.26.0416

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2219101/2022 - DEL.POL.PANORAMA, 26708101 -

DEL.POL.PANORAMA, 2219101 - DEL.POL.PANORAMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDERSON GOMES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do réu ANDERSON GOMES DA SILVA e da ré LUANA GONÇALVES DE AQUINO, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de agosto de 2022, por volta das 16h, na Rua Nicola Zwing, n 1749, Nosso Teto, nesta cidade e Comarca de Panorama, LUANA GONÇALVES DE AQUINO trazia consigo, bem como mantinha em depósito, para fins de entrega a terceiros, massa bruta total de 8,07g (oito gramas e sete centigramas) de cocaína, em sua forma petrificada ("crack"), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, fornecidas por ANDERSON GOMES DA SILVA, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Realizada audiência de custódia da ré Luana, em 12/08/2022, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, oportunidade que também fora decretada a

prisão preventiva do réu (p. 96/100), a qual foi devidamente cumprida e homologada no dia seguinte (p. 146/147).

Regularmente notificados (p. 195 e 200), os réus apresentaram as defesas prévias (Luana – p. 192/93 e Anderson – p. 206/207).

A denúncia foi recebida em 27/10/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento virtual por meio de videoconferência (p. 208/209). Durante a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como realizado o interrogatório dos réus (cf. mídia).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação dos réus, nos exatos termos da denúncia. A defesa dos réus, por sua vez, pugnou pela absolvição dos réus por inexistência de autoria e fragilidade probatória. De forma subsidiária, requereram a revogação da prisão preventiva e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão é procedente.

A materialidade está comprovada pelo APFD de p. 01/02, boletim de ocorrência (p. 12/14), pelo auto de exibição e apreensão (p. 17), pelo laudo pericial de constatação provisória (p. 21/24), pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo (p. 170/171), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é certa e recai sobre os acusados.

A testemunha policial civil Newton Jose Viana disse que estava em patrulhamento de rotina quando chegou na casa de Luana notou certo nervosismo. Indagada se havia algo ilícito, ela negou. Seu colega, em diligências, localizou 28 pedras de "crack". Indagada, Luana disse que a droga era para seu consumo pessoal e que tinha adquirido de Anderson Gomes da Silva. A droga foi encontrada no quintal, precisamente na frente da porta da cozinha. Esclareceu que a droga estava acondicionada dentro de um tênis. Depois a ré retirou, por si própria, de suas vestes, outra porção de droga. A informação era de que Luana era usuária de drogas e vendia drogas. Anderson é conhecido nos meios policiais pela prática do crime de furto (cf. mídia).

No mesmo sentido foi o depoimento prestado em Juízo pela testemunha de acusação Ricardo Takeshi Shioya, policial civil, ouvido em sede policial (p. 03), disse que policiais civis do Setor de Investigações desta Delegacia de Polícia de Panorama, juntamente com a autoridade policial titular, realizavam diligências com finalidade de identificar e localizar autoria delitiva dos diversos delitos de furto recentemente ocorridos neste município. No curso das investigações diligenciaram até o bairro conhecido como "Ninho das Cobras", mais precisamente na residência de Luana Gonçalves de Aquino, conhecido como ponto de venda de substâncias entorpecentes e aglomeração de usuários de drogas, imóvel situado na Rua Nicola Zwing 1749, nesta urbe. Referido imóvel é construído às margens da via férrea desativada. Ao chegar na residência Luana, de pronto, já demonstrou nervosismo e durante buscas e vistorias no terreno da casa, mais precisamente de frente à porta da cozinha da residência, localizou um frasco plástico escondido dentro de um tênis contendo 28 invólucros, individualizados e prontos para a mercancia, cujo conteúdo aparentava tratar-se de "crack". Ao ser indagada, Luana negou a propriedade da droga, no entanto, a mesma, espontaneamente, retirou um pequeno invólucro de suas vestes, uma porção de "crack", com embrulho semelhantes àqueles que estavam dentro do frasco plástico, e apresentou ao policial civil Newton. Ao ser indagada, alterou a sua versão apresentada inicialmente e disse que aqueles 28 invólucros encontrados no frasco e aquela que portava lhe pertenciam e seriam para consumo próprio. Luana, ainda, afirmou que teria adquirido aquelas substâncias entorpecentes da pessoa de "Andi", indivíduo que teria passado na sua casa por volta das 12h, cujas substâncias seriam para consumo. Diante aos fatos, tendo em vista as versões divergentes apresentadas por Luana; a quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, a princípio, destinadas à comercialização ilícita, foi proferida voz de prisão em flagrante delito a Luana Aquino e conduzida à delegacia de polícia. Ressalta, ainda, que não é comum um suposto usuário de substâncias

entorpecentes, pessoa humilde, adquirir a quantidade de 29 porções de “crack” para consumo, cujo valor seria de aproximadamente R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais), ou seja, R\$ 10,00 (dez reais) cada porção. Vistoriado o interior da residência, situações precárias de higiene, nada mais foi localizado. Na ocasião se encontrava a convivente de Luana, pessoa identificada como sendo Letícia da Silva Feitosa, a qual também foi encaminhada para a delegacia de polícia.

Em Juízo, a testemunha confirmou suas declarações em solo policial e acrescentou que Luana informou que adquiriu a droga de Anderson Gomes da Silva. A diligência era para apurar a prática de furto quando compareceram na casa de Luana e encontraram a droga. Anderson é conhecido nos meios policiais pela prática de delitos patrimoniais e já tinha informação de que Anderson furtava e trocava por drogas para revender (cf.mídia).

A testemunha comum Letícia da Silva Feitosa, ouvida na delegacia (p. 07), declarou que reside junto com Luana Aquino, sua companheira. A residência pertence a Luana e está situada às margens da antiga via férrea, não tem muros. Nesta data, período da tarde, policiais civis chegaram na residência perguntando sobre o paradeiro do “Andi”. Na ocasião estava na companhia de Luana. Enquanto conversava com os policiais civis, em dado momento, um outro policial civil encontrou um frasco plástico contendo diversas porções de “crack”, que estava dentro de um tênis no terreno da casa, defronte à cozinha do imóvel. Luana disse aos policiais que seria para consumo próprio. Em seguida, Luana retirou uma outra porção de crack que estava em suas vestes e entregou ao policial civil. Afirma que nesta data, por volta das 12h, o “Andi” passou na sua residência e ofereceu crack para Luana, a qual adquiriu pelo valor de R\$ 300,00, com dinheiro proveniente de um saque efetuado do auxílio que recebe mensalmente. Ao visualizar a fotografia de Anderson Gomes da Silva, apelido “Andi”, o reconhece como sendo a pessoa que compareceu à sua casa e vendeu droga “crack” para Luana. Não sabe onde “Andi” mora. Afirma que Luana é usuária de crack. Sabe que nas proximidades e na própria residência eventualmente reúnem-se usuários de drogas. Desconhece que Luana comercializa drogas.

Em juízo, Letícia da Silva Feitosa, ouvida na condição de informante do Juízo, disse que é companheira de Luana. Esclareceu que Luana comprou a droga de um indivíduo chamado “Andi” pelo valor de R\$ 300,00. A droga foi adquirida na mesma data para o consumo pessoal. Luana recebia R\$ 600,00. A depoente não tinha atividade remunerada (cf.mídia).

A testemunha de defesa, Lorival da Silva, ouvida em juízo, declarou que Anderson estava trabalhando com o depoente no dia do fato até as 17h30. Carregaram o caminhão de Ismael e depois ficaram no serviço. Recebiam seiscentos reais por semana. Anderson era usuário de drogas. Morava com o irmão do depoente. O apelido de Anderson é Anderson Gomes. Ele é conhecido como “Andi”. (cf.mídia).

A testemunha de defesa, Ismael Miqueloti, ouvida em juízo, declarou que estava trabalhando com Anderson na data do fato. Lorival é pai de Anderson. Foram em dois caminhões para Pauliceia. Carregou seu caminhão até onze e meia / meio dia. O outro caminhão que estava sendo carregado era de seu pai carregado de madeira. Anderson trabalhava para o depoente. Ele recebia noventa reais por caminhão. O réu era usuário de drogas (cf. mídia).

A ré LUANA GONÇALVES DE AQUINO, interrogada em sede policial (p. 10), declarou que reside no imóvel situado na Rua Nicola Zwing, n. 1749, bairro “Ninho das Cobras”, nesta cidade de Panorama. Convive junto com sua companheira Letícia. Afirma ser usuária de droga – crack. Nesta tarde a pessoa conhecida por “Andi” passou na sua casa e acabou comprando R\$ 300,00 para consumo próprio. Deixou algumas porções dentro de um frasco de plástico no terreno de sua casa. Nesta tarde policiais civis compareceram na sua casa perguntando sobre o “Andi” e, em dado momento um policial civil encontrou o frasco que estava dentro de um tênis, próximo à porta da cozinha da casa, contendo as 28 porções de crack que comprou de “Andi”. Durante entrevista com os policiais acabou retirando de suas vestes uma porção de crack e entregou ao policial, cuja porção seria para consumo pessoal. Afirma que não vende droga, é apenas usuária de crack e as substâncias encontradas na sua casa é para consumo pessoal.

Judicialmente, confirmou que tinha comprado a droga de Anderson para seu consumo pessoal. Anderson passou a droga do jeito que estava lá. A droga que estava em suas vestes estava usando. Comprou a droga de Anderson para seu uso. A rua é muito frequentada e o rapaz que residia anteriormente na casa autorizava usuários de drogas no local. A quantidade para quem é usuário não é muita. Anderson frequentava sua casa sempre e ele era usuário. Como fazia bicos, a ré sempre tinha dinheiro. Anderson frequentava sua casa para usar e fornecer drogas. A droga de Anderson era para venda. Pagou R\$ 300,00 pela droga. Deixava Anderson usar sua casa. Anderson chegava com droga para usar e quando chegava alguém para usar, ele buscava a droga. Tem dois filhos que moravam com sua mãe. Usava de trinta a quarenta "paranga" por dia. O dinheiro era do seu benefício. Esclareceu que Anderson não comercializava droga em sua casa. Anderson usava como fumódromo e se aparecesse alguém para comprar ele buscava para a pessoa (cf. mídia).

Em seu interrogatório judicial, o réu ANDERSON GOMES DA SILVA disse que trabalhava a semana inteira para usar droga no final de semana. Quando saiu da cadeia, praticou furto e roubo. Conhece a ré, mas não passou nada para ela. Nunca passou droga para a ré vender. Sempre trabalhou. Não pegou dinheiro da ré Luana. É usuário de "crack". Estava morando com seu tio. Já frequentou a casa de Luana para usar a droga. Nunca forneceu droga para Luana. Quando chegava na casa dela, ela perguntava se tinha alguma coisa aí. Já fumaram juntos, mas nunca deu troca para Luana vender. Não tem filhos. Ganhava R\$ 550,00 por semana (cf. mídia).

De toda instrução, vislumbro que a negativa dos réus não merece crédito, pois divergente do arcabouço probatório produzido, com nítida intenção de eximirem-se da responsabilidade pelo ilícito praticado. O conjunto probatório produzido indica que a substância entorpecente apreendida pertencia à ré Luana, que por sua vez adquiriu do réu Anderson e se destinava à traficância.

Isso porque, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil da substância entorpecente: (a) a natureza e a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, a saber: 29 invólucros de crack, pesando 08 gramas; (b) forma de acondicionamento típico de venda à varejo; (c) laudo pericial do local onde foi encontrada a droga (p. 166/168).

Segundo o apurado, os policiais civis Ricardo e Newton, durante diligência com a finalidade de identificar a autoria delitiva de diversos furtos que estavam ocorrendo no município, deslocaram-se até o bairro como "Ninho da Cobras", mais precisamente na residência de Luana, ponto conhecido de venda de drogas e aglomeração de usuários. Ao chegarem no local, a ré já demonstrou certo nervosismo e desconforto com a presença dos policiais e durante as buscas no imóvel, localizaram um frasco de plástico contendo 28 pedras de "crack" que estava escondido dentro de um tênis, na área externa da residência. Indagada, Luana inicialmente negou a propriedade da droga, mas ato contínuo retirou de suas vestes uma porção com embrulho semelhante àqueles que estavam dentro do frasco plástico, e assumiu a propriedade da droga, bem como disse que seriam destinadas ao consumo pessoal. Luana afirmou que tinha adquirido aquelas porções da pessoa conhecida como "Andi", posteriormente identificado como o réu Anderson Gomes da Silva, o qual teria fornecido a droga diretamente na casa dela, por volta das 12h daquele dia, pelo valor de R\$ 10,00 cada porção.

Pois bem.

Ressalte-se que os testemunhos dos Servidores Policiais em Juízo são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, sobretudo o laudo definitivo de substância entorpecente, comprovar a ocorrência do fato típico e embasar um decreto condenatório ao réu, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado os depoimentos na fase inquisitorial.

Portanto, não há razão suficiente a invalidar o depoimento dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de deporem, só porque ostentam essa qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito. A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de

tráfico.

Nesse sentido:

'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido'. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111)

'TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos'. (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.)" (TJSP, Apelação nº 3005426-36.2013.8.26.0082, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. FRANCISCO GALVÃO BRUNO, j. 31.03.2016).

A versão da acusada, de que a droga apreendida seria para seu uso, todavia, não pode ser tida como verossímil, eis que restou isolada e sem amparo nos demais elementos de convicção produzido nos autos. Vejamos:

É certo que tanto em sede policial como em juízo a ré narrou que teria adquirido a droga diretamente da pessoa do réu, tendo pago R\$ 290,00, ou seja R\$ 10,00 por cada porção. Contudo, primeiro ponto que afronta sua tese é o local onde foi armazenado o entorpecente, dentro de um frasco, escondido num ténis que estava na área externa do imóvel, desprovido de muros, conforme se vê às p. 166/168, ou seja, se fosse verdade que a droga seria usada no consumo próprio, não teria motivo para escondê-la fora de casa e correr o risco de alguém.

Com efeito, segundo ponto a ser frisado é que não é comum para um usuário de "crack", ter a seu dispor expressiva quantia em dinheiro, bem como, bem como verifico que a ré não comprovou nos autos que exerce alguma atividade lícita remunerada, tudo a indicar que se dedicava e fazia do tráfico seu meio de vida. De outra parte, a circunstância de ser o réu usuário de drogas também não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, pois nada impede que as figuras de usuário e traficante recaiam sobre a mesma pessoa.

No mesmo sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, Acr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES: "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e suas condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Ade ler. Al. Legislação Criminosa Especial. VI. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197)."

A propósito, convém transcrever que a decisão publicada na RT 546/327, para a confecção de uma porção individual de cocaína é necessário 0,01 grama ou 0,1 grama, a depender se consumida por via endovenosa ou por aspiração, o que indica que a cocaína que estava em poder do réu, cujo peso totalizava 8,07 (oito gramas e sete centigramas), era suficiente para a confecção de mais de 807 (oitocentos) porções

individuais!

Isso deriva do seguinte entendimento: "por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração, a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente" (Legislação Penal Especial, Editora Atlas, 3ª edição, São Paulo, 2000, citando julgado colacionado na RT 546/327).

É importante ressaltar também que a quantidade de substância entorpecente apreendida não define, por si só, a condição de traficante ou usuário. Aliás, os traficantes muitas vezes não são encontrados com grande quantidade de entorpecente, pois, se de um lado não pretendem correr o risco de perder tudo diante de uma abordagem policial, de outro, a pequena quantidade pode ser facilmente homiziada e vendida separadamente aos usuários.

Por isso, não prospera a tese de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, motivo pelo qual fica afastada a pretensão de absolvição por fragilidade probatória ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Frise-se, ainda, que a delação do comparsa goza de relevante valor probante, servindo como especial elemento de prova, uma vez que além de apontar os coautores, auto-incrimina-se sem apresentar excusas para o fato delituoso, sendo, pois, apto para sustentar o decreto condenatório.

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente circunstanciado - Emprego de arma de fogo e concurso de agentes - Pleito defensivo de um dos corréus colimando a absolvição - Inadmissibilidade - Provas contundentes da autoria delitiva de ambos os sentenciados - Confissão/delação de um dos corréus que está em sintonia com as demais provas produzidas ao longo da instrução - Negativa de autoria que não se sustenta - [...] (TJSP; Apelação Criminal 1503059-05.2019.8.26.0535; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

No caso presente, a versão da ré de que adquiriu a droga do réu Anderson foi corroborada pelos depoimentos da testemunha Letícia da Silva Feitosa e do policial civil Ricardo Takeshi (cf. mídia).

Nesse contexto, a julgar pela quantidade, natureza e a forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida, a saber, 29 porções da substância "CRACK", denotam claramente sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, Acr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Ainda, importante consignar que, em se tratando o tipo penal de tráfico de drogas de conteúdo variado ou misto alternativo, qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Dessa forma, ainda que o réu não tivesse sido flagrado comercializando a substância entorpecente, o simples trazer guardar drogas é suficiente para que se configure o tráfico ilícito de drogas, sendo dispensável a oitiva de eventuais compradores usuários.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se

fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes dos agentes." (RT 584/347).

Portanto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente precisa ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Assim, os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, aliado às provas que se produziu em Juízo, são suficientemente harmônicos e aptos a ensejar a condenação dos réus pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, pois demonstrado que infringiram a norma do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, por, ao menos, vender e manter em depósito substância entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, bem como em vista a natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, incompatível com o porte para consumo pessoal, tudo indicando claramente o tráfico.

Diante do conjunto probatório não há como se acolher o pleito de desclassificação para o crime do artigo 28 ou artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória.

Em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à necessária dosimetria (CRFB, art. 5º, XLVI).

Da ré Luana Gonçalves de Aquino

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não se verificam circunstâncias judiciais desfavoráveis. De outra parte, considerando que há previsão legal expressa permitindo ao juiz, na fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (artigo 42 da Lei nº 11.343/06). Assim, considerando a natureza da droga apreendida (crack), de fácil disseminação e de efeitos catastróficos aos seus usuários, há maior grau de censurabilidade à conduta, razão pela qual exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto), totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

A propósito:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A motivação adotada pelo Tribunal a quo para fixar a pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada e suficiente. Foram indicados elementos concretos que demonstram serem desfavoráveis as circunstâncias do crime, ressaltada a grande quantidade de entorpecentes apreendida (96 papelotes de cocaína). 2. Em consequência, não se mostra possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, tendo-se presente que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e a pena imposta é de 8 (oito) anos. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 124554 MS 2008/0282818-9, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, DJ: 22/08/2011, 6ª T, Data de Publicação: DJe 31/08/2011)".

"(...) No crime de tráfico de drogas, não há ilegalidade no aumento da pena-base se nas instâncias ordinárias esclareceu-se ter sido grande a quantidade de droga apreendida (no caso, 18 pedras e 4 pedras grandes de crack, 65 papelotes de cocaína, 01 bucha de maconha) e variada a natureza. O art. 42 da Lei n.º 11.343/06 é expresso no sentido de que o "juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto". (STJ - HC: 214180 ES 2011/0172672-2, Relator: Ministra Laurita Vaz, DJ 22/10/2013, T5 DJe 05/11/2013)".

Na segunda fase de dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase do cálculo da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a reprimenda no mesmo patamar. Vale ressaltar que, em que pese a primariedade do réu, o presente caso não se subsume às hipóteses de aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque tal privilégio foi previsto aos agentes primários que possuem bons antecedentes e não

se dediquem às atividades criminosas nem integrem organização criminosa, o que não é o caso, já que a expressiva quantidade e natureza da droga apreendida em poder da ré, a saber, 29 invólucros de "crack", indica que era pessoa que se dedicava à atividade criminosa, pois se toda a quantidade de droga encontrada com a ré entrasse em circulação, certamente destruiria a vida de muitos jovens e suas respectivas famílias.

A propósito, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a quantidade, a diversidade e a natureza da droga justificam a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Confira-se:

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME MAIS BRANDO. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL DE N.º 1444115-3 3ª CCRIMINAL 3. Caso em que a expressiva quantidade de droga encontrada (120kg de maconha) demonstra a dedicação do paciente às atividades criminosas e afasta a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, enfraquecendo a alegação de ocorrência de bis in idem. Precedentes do STF. (...) (STJ, HABEAS CORPUS Nº 308.682 - MS (2014/0293393- 8), rel. Min. Gurgel De Faria, julg. 08/09/2015)."

"HABEAS CORPUS' SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. PRECEDENTES. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do 'habeas corpus' e não mais o admitem como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2. O Tribunal 'a quo' adotou o fundamento de que diante das circunstâncias da prisão, dos apetrechos e das drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de 'crack') , tudo a evidenciar dedicação à vida delituosa, não há como se aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 3. 'Habeas corpus' não conhecido por ser substitutivo do recurso cabível (HC 173.574/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 15/08/2014). No mesmo sentido: HC n. 259490/RJ - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) - DJe 18/6/2014; AgRg no Resp n. 1340528/SC - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Jorge Mussi - DJe 11/6/2014; HC n. 292971/SP - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - 04/06/2014; HC n. 271.575/SP - 5ª T. - unânime - Rel. Min. LAURITA VAZ - DJe 11/09/2013."

Assim, torno definitiva a reprimenda em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Baseado no critério da situação econômica da ré, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59 do Código Penal, tendo em vista que o tráfico ilícito de substância entorpecente é conduta das mais deletérias, que atenta contra a saúde e até mesmo a vida de considerável parcela da população, composta basicamente por jovens adolescentes, os quais, uma vez iniciados no vício, raramente dele conseguem se livrar. Além disso, se constitui em porta aberta para o cometimento de outros crimes, notadamente voltados contra o patrimônio, sabido que não raro usuário destituído de capacidade econômica subtrai bens alheios para conseguir dinheiro para sustentar o vício. Cuida-se, ademais, de conduta equiparada a crime hediondo. Mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Tudo, enfim, a justificar maior rigor na retribuição.

No que diz respeito à substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, apesar da recente Resolução nº 5 editada pelo Senado Federal, através da qual ficou suspensa a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" presente no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sua aplicação não seria possível diante das circunstâncias do caso concreto, pois não se mostra medida

suficiente e adequada. Os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos. Tal delito vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente".

Assim, embora o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, por serem os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal cumulativos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal.

Este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou." (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

Pelo montante da pena aplicada, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Do réu Anderson Gomes de Silva

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu apresenta maus antecedentes, pois possui mais de uma condenação com trânsito em julgado, consoante se vê às p. 68/76, demonstrando que já foi codenado por sentença definitiva pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal (Autos nº 0000092-29.2015.8.26.0591 – p. 68), razão pela qual exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto), totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante genérica da reincidência, pois o réu apresenta condenação com trânsito em julgado em razão da prática do crime previsto no artigo 157, "caput", do Código Penal (Autos nº 000224-86.2015.8.26.0591 – p. 68), razão pela qual exaspero a pena em 1/6, totalizando 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase do cálculo da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a reprimenda no mesmo patamar. Vale ressaltar que o presente caso não se subsume as hipóteses de aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque tal privilégio foi previsto aos agentes primários que possuem bons antecedentes e não se dediquem às atividades criminosas nem integrem organização criminosa, o que não é o caso, já que o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes. Ademais, o acusado vendeu o entorpecente "crack", tudo a indicar a sua dedicação às atividades criminosas, fazendo do tráfico ilícito um modo de vida, o que impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da situação concreta do delito, de extrema gravidade. Se essa quantidade de droga entrasse em circulação, certamente destruiria a vida de muitos jovens e suas respectivas famílias.

A propósito, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a quantidade, a diversidade e a natureza da droga justificam a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, torno definitiva a pena em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos

Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59 do Código Penal, em razão da reincidência específica, dos maus antecedentes e da conduta social reprovável do réu, aliado ao fato de que o tráfico ilícito de substância entorpecente é conduta das mais deletérias, que atenta contra a saúde e até mesmo a vida de considerável parcela da população, composta basicamente por jovens

adolescentes, os quais, uma vez iniciados no vício, raramente dele conseguem se livrar. Além disso, se constitui em porta aberta para o cometimento de outros crimes, notadamente voltados contra o patrimônio, sabido que não raro usuário destituído de capacidade econômica subtrai bens alheios para conseguir dinheiro para sustentar o vício. Cuida-se, ademais, de conduta equiparada a crime hediondo. Mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Tudo, enfim, a justificar maior rigor na retribuição.

Considerando o montante de pena aplicado, bem como que o réu é reincidente específico e ostenta maus antecedentes e conduta social reprovável, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelos mesmos motivos, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP). Ademais, tais institutos, além de se mostrarem incompatíveis com o regime fechado fixado para cumprimento da pena, não se mostram socialmente recomendáveis e suficientes à repressão do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de ação penal, e assim o faço para CONDENAR o réu ANDERSON GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, e a ré LUANA GONÇALVES DE AQUINO, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estarem incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à conversão/decretação da prisão em flagrante em prisão preventiva dos acusados, aos quais faço referência a fim de evitar repetições desnecessárias (fls. 96/100), bem como considerando que a necessidade da prisão cautelar foi realçada pelo decreto condenatório e regime de pena ora definidos, tendo em vista a natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida em poder do réu e em se tratando de réu reincidente específico e possuidor de maus antecedentes e conduta social reprovável, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, MANTENHO a custódia cautelar dos acusados, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se os réus na prisão em que se encontram.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens eventualmente apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Transitado em julgado: a) expeça-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Se o caso, na forma do previsto no artigo 58, parágrafo 1º, da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial para que providencie a incineração das drogas apreendidas, preservada quantidade suficiente para eventual contraprova, aguardando-se o trânsito em julgado.

Oportunamente, intimem-se para efetuar o pagamento da multa. Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Panorama, 22 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA